

친밀한 관계에서의 폭력에 대한 형사정책의 법적 정당성 검토 - 가정폭력, 스토킹, 데이트폭력을 중심으로

김 해 미*

국 | 문 | 요 | 약

최근 가족이나 연인 관계에서 일어나는 폭력에 대해 신속하고 효율적으로 대응하려는 논의가 활발히 전개되고 있다. 본 논의에서는 이를 친밀한 관계에서의 폭력(Intimate partner violence) 개념을 통해 논하면서 가정폭력, 데이트폭력, 스토킹을 다루고 있다. 친밀한 관계에서의 폭력에 관한 연구는 친밀한 관계의 폭력 피해자들이 스스로를 보호하거나 법적 구제를 구하는데 어려움을 겪는다는 사실을 지적한다. 종래에는 이를 개인의 사적 영역으로 존중해야 한다고 보았으나, 관계의 특성을 고려하여야 한다는데 사회적 합의가 형성되며 국가가 적극적으로 개입하기를 촉구하고 있다. 본 논의는 현행법인 가정폭력처벌법과 스토킹처벌법을 비교분석하고 데이트폭력처벌법의 제정논의로 논의를 확장하며 법적 규율의 경향을 탐색하고 있다.

친밀한 관계의 폭력을 규율하는 현행법은 법체계와 구조에서 유사성이 있다. 가정폭력처벌법과 스토킹처벌법은 대응 조치로 경찰의 응급조치와 긴급임시조치(긴급응급조치), 검사가 청구하는 임시조치(잠정조치) 등을 규정하고 있다. 데이트폭력처벌법의 제정 논의도 이와 같은 구조를 따르고 있다. 이들은 적용범위, 행위주체와 객체가 각기 달라 분명한 차이점도 있는데, 최근 친밀한 관계의 폭력을 다루는 정책은 전반적으로 피해자 보호를 위해 강력한 조치를 취하는 공통적인 경향을 보이고 있다. 특히 이 같은 조치는 주로 제재 강화와 엄벌에 치중하는 양상으로 전개되고 있다. 본고는 분리조치의 강화나 반의사불벌죄의 폐지나, 조치위반의 형사화 현상에 대해서 고찰하였고 스토킹처벌법상 잠정조치의 일환으로 위치추적 전자감독 장치를 부과한 것이나, 가정폭력처벌법에서 감호위탁처분을 도입한 바를 검토하였다. 엄벌주의적 조치나 형벌 이외의 제재로 피해자 보호를 실현하는 것은 중요하나, 제재적 성격은 강력한 반면 법적 정당성이 모호한 영역이 있다. 이 같은 정책은 목적 달성에는 실효적일 수 있으나, 감시적 이거나 인신구속적인 제재를 우선적으로 활용하는 것은 형벌의 과잉이 될 수 있다. 피해확산의 방지가 강조될지라도 정책에 대한 법적 정당성에 대한 검토는 신중히 이루어져야 한다. 또한 범죄의 특성과 차이를 도외시하고 일률적인 내용을 규정하는 것도 타당하지 않다. 이 같은 정책들이 실효적이면서도 법적으로 정당한지 신중하게 검토해야 할 것이다.

DOI : <https://doi.org/10.36889/KCR.2024.3.31.1.55>.

❖ 주제어 : 친밀한 관계에서의 폭력, 가정폭력, 데이트폭력, 스토킹, 위치추적 전자장치

* 고려대학교 형사법전공 법학박사

I. 문제의 제기

최근 한국사회에서는 가족이나 연인 관계에서 일어나는 사건을 어떻게 치우해야할지에 대한 논의가 활발히 전개되고 있다. 배우자간, 또는 연인 간에 일어나는 가정폭력, 스토킹, 데이트폭력 등의 사건들이 연일 보도되어 사회에 커다란 충격을 안기며 그 피해의 심각성과 중대성에 대한 관심이 촉발되었다. 이를 예방하기 위해 강력한 형사법적 대응이 필요하다는 목소리가 높아지며 법의 제·개정 논의도 신속히 이뤄지고 있다. 가정폭력을 규율하는 가정폭력처벌법은 1991년 제정되었는데 최근 들어 법적 논의가 더욱 활발하다. 스토킹을 처벌하는 스토킹처벌법이 2021년 제정되었으며 데이트폭력을 규율하는 법을 제정해야 한다는 논의도 계속되고 있다.

이와 같은 사건들은 과거에도 중대한 피해를 야기하였고 그 심각성에 대한 문제의식이 있었으나, 국가가 적극적으로 대처해야 한다는 여론이 높아진 것은 비교적 최근으로 볼 수 있다. 그 배경을 미디어 보도의 확산, 인터넷 기술의 발달 등으로 들 수 있겠으나, 보다 근본적으로는 개인의 사적인 영역이라고 생각했던 가족, 연인 관계의 영역에 국가가 함부로 끼어들 수 없다는 종래의 인식이 전환되고 있기 때문일 것이다. 최근에는 국가가 이 같은 영역에 적극적으로 개입해 가해자를 처벌하고 피해자를 보호하고 있다. 이전에는 단순한 구애행위의 일종으로 생각했던 스토킹 행위를 형벌로 처벌하게 된 것도 이 같은 인식 전환에서 기인한다. 이는 형법적 관점에서는 영역의 확장으로도 볼 수 있다. 사적인 문제라고 보았던 행위들이 사회적 인식의 변화에 부응하여 형법의 영역으로 포섭되고 있는 것이다.

해외에서는 일찍이 이를 친밀한 관계에서의 폭력으로 정의하면서, 여성 피해자의 입장을 고려하여 가족 또는 연인과 같은 가까운 사이에서 위해를 가하는 행위를 범죄로 규정하고¹⁾ 신속하고 효율적으로 예방할 것을 논하였다. 친밀한 관계에서 일어나는 폭력은 일반적으로 현재의 혹은, 이전의 친밀한 파트너에 의한 폭력을 불문하는 개념으로, 여기서 말하는 폭력은 물리적 폭력, 성적 폭력, 스토킹, 통제 기술을 포함한 심리적 공격

1) 한국에서는 Intimate Partner Violence(IPV)를 친밀한 관계에서 일어나는 폭력으로 번역하고 있다. 본고에서는 이를 친밀한 파트너가 가하는 폭력으로 정의하고, 이를 친밀한 관계에서의 폭력으로 칭하고자 한다.

을 포함한다. 친밀한 관계의 폭력은 즉각적인 위해를 가할 뿐만 아니라, 일생 동안 영향을 미치는 결과를 낳을 수도 있다. 많은 연구결과에서 친밀한 관계의 폭력 피해자들은 상해나 사망을 넘어 극심하고 만성적인 정신적·육체적인 고통을 경험하는 것으로 나타났다.²⁾ 해외 학계에서는 친밀한 관계에서 일어나는 폭력의 성격과 유형을 연구하고 그 정책적인 대응 방안을 연구하고 있다.

국내의 현행법도 친밀한 관계에서 발생하는 폭력에 적극적으로 대응하려는 노력을 기울이고 있다. 그런데 법 개정 속도는 매우 빠른 반면, 형사법적 정당화에 대한 고찰이 심도 있게 행해지고 있지 않다는 점을 비판적으로 고찰하고자 한다. 친밀한 관계에서의 폭력을 다루는 현행법들은 체계적으로 유사한데, 그 내용에서도 공통적 경향성이 드러난다. 문제는 각 법이 공통적으로 엄벌주의적으로 강화되는 양상을 보인다는 점이다. 물론 실효적인 대응이 필요하나, 이는 법적 정당성에 대한 검토가 반드시 수반되어야 함에도 이에 대한 충분한 고려는 없는 듯하다. 본고에서는 각 법의 구조와 여러 조치를 검토하면서 엄벌주의 경향을 포착하고 법적 정당화를 위해 제재 성격은 보다 완화되거나 실효적인 수단을 취할 것을 우선적으로 요청하고 있다. 또한 친밀한 관계의 폭력 유형별 차이를 도외시하고 일률적으로 강화된 제재를 취하기보다 관계의 특성을 고려해 규율하여야 한다고 주장하고 있다.

이 같은 논증을 위해 친밀한 관계에서 발생하는 폭력 개념을 논하는 이유를 다루고 (1) 친밀한 관계의 폭력으로 정의되는 문제를 규율하는 현행 가정폭력처벌법, 스토킹처벌법을 분석하고, 데이트폭력처벌법의 입법 논의를 살펴 법체계의 유사성을 검토한다. (2) 이 같은 법에서 공통적으로 나타나는 엄벌주의적 경향을 분석한 후 최근 개정안으로 도입된, 또는 도입논의 중인 정책의 형사법적 타당성을 검토한다. (3) 결론적으로, 가족 또는 연인 사이의 관계에서 발생할 수 있는 문제에 대한 국가 개입의 방향성에 대해 제안하고자 한다.

2) Breiding, M.J., Chen J., & Black, M.C., Intimate Partner Violence in the United States - 2010. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention, 2014, p.7.

II. 친밀한 관계에서의 폭력(Intimate partner violence) 논의의 의의

1. 미국의 ‘친밀한 관계의 폭력’ 논의의 연혁

친밀한 관계를 맺은 파트너에게 폭력을 입은 경우를 개념화하고 연구하기 시작한 시점은 1960년대 미국에서 매맞는 여성 증후군(Battered Woman Syndrome)이 문제로 대두되고, 가정폭력 등 여성폭력 문제를 논하기 시작하면서부터라고 할 수 있다.³⁾ 파트너에게 폭력을 당한 피해자들이 왜 적극적으로 저항하지 못하고 심리적으로 무력해지는가에 대한 분석이 잇따랐고⁴⁾ 1962년 뉴욕 주에서 미국 최초로 보호명령법이 제정되었다. 1970년대 중반부터 여성인권단체를 중심으로 친밀한 관계의 폭력에 대한 경찰의 대처에 비판하는 움직임이 있었는데, 경찰이 가정폭력사건에의 개입을 중요치 않게 생각하고 다른 폭력사건과 비교하면 행위자를 적극적으로 체포·구속하려하지 않는다는 것이었다.⁵⁾

1977년 이후부터 뉴욕 주는 보호명령법의 입법목적을 ‘가족에 대한 폭력방지’로 규정하고 캘리포니아 주는 ‘폭력행위와 성적 학대의 재발을 방지하고 가정폭력의 당사자를 분리시킬 것’으로 규정하는 등 가정폭력에 대해 법적으로 규율하기 시작하였다. 1990년대 이후부터는 학교 캠퍼스 내에서의 데이트 폭력 문제가 중요한 이슈로 대두되면서 활발하게 논의되기 시작하였고 각 주마다 스토킵보호명령제도나 성폭력피해자보호명령제도 등을 규정하기 시작하였다. 친밀한 파트너에게 당하는 폭력을 법으로 규율해야 한다

3) Flynn, S, Battered Woman's Syndrome: A Tragic Reality, an Evolving Theory. *Trinity Women & Gender Minorities Review*, 3(1), 2019, p.39-40. 1960년대와 1970년대에 여성주의 운동이 가정폭력에 대한 사회의 통념에 도전하면서 이 같은 논의가 시작되었다.

4) 이는 미국의 형사판례에서도 법적 쟁점으로 등장하였다. 이른바 매맞는 여성(Battered Women) 피고인들이 Walker의 Cycle theory(1979)를 바탕으로 Self-defense(자기방어)의 법리를 주장하였다. 여성들이 스스로 학대관계를 벗어날 수 없었음을 법적 쟁점으로 주장하였다. David L. Faigman, *The Battered Woman Syndrome and Self-defense: A Legal and Empirical Dissent*, 72 *Va. L. Rev.* 619, 1986, p.628-629에서 인용함.

5) 윤정숙 외 5인, 「가정 내 폭력범죄 감소 및 예방을 위한 사회안전망 강화에 관한 연구」, 형사법무정책연구원, 2017, 467면.

는 논의가 촉발되면서 1994년 연방 여성폭력방지법이 제정되었다.⁶⁾ 여성폭력방지법은 가정폭력 문제를 규율하고 데이트폭력, 스토킹 문제로 넓혀가며⁷⁾ 피해자 보호의 범위를 확대하였다. 해당 법률은 여성을 대상으로 한 폭력범죄의 처벌 및 피해자에 대한 보호, 지원조치에 대하여 연방정부 차원에서 광범위하고 일관성 있는 기반을 마련하고자 하였다.⁸⁾ 이 같은 종류의 폭력에 대해 국가가 개입함으로써 사회적 안전망을 확보해야 한다는 문제의식이 확산되었고 이는 친밀한 관계에서의 폭력 연구를 본격화하였다.

2. 논의의 의의와 연구 범위

가. 법적 관점에서 본 논의의 필요성

‘친밀한 관계에서의 폭력’에 대한 학계의 연구가 발전하였지만 이는 법적으로 정의될 수 있는 개념은 아니다. ‘친밀한’ 관계를 개념화할 요소가 분명치 않아 의견이 통일되지 않기 때문이다. 그럼에도 법학적 관점에서 논의를 전개할 필요가 있는지 논하고자 한다. 친밀한 관계의 폭력에 대한 연구는 일반적인 유형의 범죄에 비해 친밀한 관계의 폭력에서 두드러진 특징을 들고 있는데, 이 같은 폭력을 당하는 피해자들이 법의 구제를 받기가 더 어렵다는 것이다.⁹⁾ 종래에는 국가가 개인이 친밀한 파트너와 맺는 관계에 개입하는 것이 자제되어야 한다는 발상이 더 우세했는데, 친밀한 관계에서 종종 일어나는 다름은 거의 사적인 문제로 생각되었기 때문이다. 만약 피해가 중대했다면 피해자가 스스로 목소리를 낼 것이며 사법상의 구제를 구할 것이라 보았다. 그런데 이 같은 관계에서 피해자들이 스스로를 보호하기 어렵다는 연구결과들이 제시되었다. 친밀한 관계에서의 폭력은 생명을 위협하는 수준에 이르기까지 하는데, 미 연방 수사국의 2000년 연구에서는

6) 홍영오·연성진·주승희, 「여성 대상 폭력에 관한 연구 - 친밀한 관계에서의 폭력을 중심으로 -」, 형사법무정책연구원, 2015, 349면.

7) 홍영오·연성진·주승희, 같은 보고서, 349-350면.

8) 김구슬, “데이트폭력범죄에 대한 입법적 대응방안”, 이화젠더법학, 제9권 제3호, 2017, 146면; 홍영오·연성진·주승희, 「여성 대상 폭력에 관한 연구 - 친밀한 관계에서의 폭력을 중심으로 -」, 형사법무정책연구원, 2015, 349면.

9) Jordan, Carol E. “Intimate partner violence and the justice system: An examination of the interface.” *Journal of interpersonal violence* 19.12, 2004, p.1412.

매년 살해당하는 여성의 30% 이상이 남편 또는 남자친구에 의해 살해당하고 있다고 보고했다.¹⁰⁾ 폭력 피해를 당한 피해자들은 신체적 폭력뿐 아니라 부정적인 정서적인 반응을 겪고, 폭력 피해 여성의 31%에서 84%가 외상후 스트레스장애(PTSD)를 겪고 있다는 연구결과가 있었다.¹¹⁾ 이처럼 피해자들은 신체적·정서적 폭력으로 인해 무력함을 느끼거나 취약한 처지에 놓여 적극적으로 대처하기 어렵다. 사법적 구제를 구하는 것 역시 그러하다. 가해자와 안면이 있는 경우에 피해자들이 법적 구제를 받기가 더 어렵다는 실제적인 증거가 있다는 점을 고려한다면, 친밀한 관계에서의 폭력 피해자들은 이 같은 어려움을 더 강하게 겪을 가능성이 있다. 가해자와 깊은 인적 관계를 맺었기 때문이다. 또한 형사소송 절차를 살펴보면 친밀한 관계에 있었던 가해자에게 피해자가 직접 노출되는 경우가 많고 절차 중 피해자들은 안전한 환경에서 법의 구제를 기다리는 것이 아니라 스스로의 신빙성을 입증해야 한다.¹²⁾ 이 과정에서 가해자의 위협에 시달릴 확률이 높아 법적 구제를 구하기 쉽지 않다.

가정폭력을 당하는 피해자의 경우 가정이 심리적·경제적 삶의 기반이기 때문에 폭력을 당하더라도 가해자를 처벌하기를 원치 않거나 가해자의 처벌로 기반을 상실하는 것을 두려워하기도 한다. 이 때문에 피해자가 적극적으로 대처하기를 주저하기도 한다. 사회적 분위기와 문화도 영향을 미친다. 데이트폭력의 경우 사랑과 성에 관한 낭만주의적 사랑관과 이에 기인한 잘못된 인식이 데이트폭력에 대한 올바른 대처를 저해하는 요인이 된다. ‘상대방의 의사와 무관하게 불쑥 집으로 찾아오거나 집 앞에서 하염없이 기다리는 것은 낭만적’이라거나 ‘여자친구를 때릴 정도로 남자의 사랑이 깊어질 수도 있다’라는 생각은 사랑 때문에 폭력을 가하는 것이라고 폭력을 정당화하기도 한다. 연인 사이인 파트너를 때리는 것은 일종의 사랑싸움이므로 제삼자가 개입할 문제가 아니라는 인식 때문에 데이트폭력에 제대로 대응하지 않고 이를 감내하는 경우도 있다.¹³⁾ 스토킹은 종종 인적 관계에 대한 집착 때문에 발생하는데¹⁴⁾ 가해자의 강한 인적 집착이 심각한 피해로

10) 서경현, “이성관계에서 행해지는 데이트 폭력에 관한 연구의 개관”, 한국심리학회지: 건강 제14권 제4호, 2009, 701면에서 인용.

11) Sabina와 Straus의 2008년 연구를 위의 서경현, 같은 논문, 같은 면에서 재인용.

12) Jordan, Carol E. “Intimate partner violence and the justice system: An examination of the interface.” *Journal of interpersonal violence* 19.12, 2004, p.1412.

13) 홍영오·연성진·주승희, 같은 보고서, 327-331면.

14) 김구슬, “데이트폭력범죄에 대한 입법적 대응방안”, 이화젠더법학, 제9권 제3호, 2017, 142면.

변질 수도 있다는 두려움 때문에 적극적으로 대처하기 어려울 것이다.

물론 친밀한 관계에서 발생하는 폭력도 기존의 실정법으로 규율할 수 있다. 그러나 관계의 특성상 기존의 실정법으로 보호받기 어려운 영역이 있다. 친밀한 관계에서 발생하는 폭력 개념은 이 같은 이유들을 토대로 국가가 기존의 틀을 벗어날 것을 요청한다. 이는 현대사회에서는 친밀 관계의 범주와 친밀성의 의미가 확장되고 그 양상이 변화하고 있는데, 혼인 및 혈연관계나 전통적인 가족관계에 한정된 방식으로 폭력 문제에 접근하고 있어 한계가 있다고 주장한다.¹⁵⁾ 국가가 이 같은 문제에 미온적으로 접근할 경우 가해자로 하여금 왜곡된 인식과 잘못된 확신을 갖게 하여 피해자를 더 큰 위험에 빠뜨린다는 비판도 있다.¹⁶⁾ 이 같은 문제의식은 정책이 친밀한 관계에서의 피해자를 적극적으로 보호하는 방향을 추구하도록 기반을 제공하고 친밀한 관계에서의 폭력을 통합적으로 살펴 대응해 나갈 것을 요청한다.

나. 연구의 범위

친밀한 관계에서의 폭력은 여성 폭력에 대한 문제의식을 바탕으로 논의되기 시작하였고, 법적인 논의는 미국에서 1994년 여성폭력방지법이 제정된 것을 계기로 본격화되었다. 이처럼 친밀한 관계에서의 폭력 논의는 여성에 대한 보호 촉구를 계기로 시작되었으나 법적인 관점에서는 초점을 수정할 필요가 있다. 법은 가해자와 피해자 사이에서 일어나는 행위를 규율한다. 본 논의는 그 중에서도 친밀한 파트너(partner)에 가하는 폭력에 초점을 맞추고, 법 정책을 검토한다. 친밀한 파트너는 배우자 또는 연인을 지칭하고, 친밀한 관계에서의 폭력은 배우자이거나 배우자였던 관계, 그리고 데이트 관계를 맺은 사람 사이에서 일어나는 폭력을 그 대상으로 한다. 따라서 파트너 관계에 있다면 남성이나 성소수자도 그 대상으로 포섭할 수 있다.

본 논의에서는 가정폭력, 스토킹, 데이트폭력의 법과 정책 중 친밀한 파트너 간에 일어나는 폭력에 한정해 이들을 분석하고 평가하기를 시도한다. 이 세 가지 유형의 정책

15) 김효정, “젠더기반폭력으로서 친밀 관계 폭력의 특성과 쟁점: 현장의 지원 경험을 중심으로”, 한국여성학 제40권 제1호, 2024, 251면.

16) 허민숙, “국가가 초래한, 국가가 알지 못하는 위험: 친밀한 관계에서의 강압적 통제”, 한국여성학 제37권 제1호, 2021, 225면.

규율이 모두 친밀한 관계에서의 폭력을 다룬다고는 할 수 없다. 가정폭력은 배우자에 대한 폭력뿐만 아니라 가족구성원에 대한 폭력도 규율한다. 스토킹은 가정폭력이나 데이트 폭력처럼 가해자와 피해자 간의 관계를 전제로 하는 것이 아니라, 그러한 관계에서 일어나는 다양한 행위 유형 중 하나로 볼 수 있다. 따라서 가정폭력이나 스토킹범죄에 대한 정책 일반을 친밀한 관계에서의 폭력과 관련한 정책으로 볼 수는 없다. 이러한 한계에도 불구하고 친밀한 관계에서의 폭력이라는 개념을 기반으로 법을 분석하고 평가하는 것은 개념이 갖고 있는 문제의식을 바탕으로 각 법을 통합적인 시각에서 살펴 공통적인 경향성을 포착하고자 함이다. 그리고 이를 바탕으로 정책적 대응을 평가하고 타당한 방향을 모색하고자 한다.

Ⅲ. 친밀한 관계에서의 폭력을 다루는 현행 법 분석

1. 가정폭력처벌법과 스토킹처벌법의 비교

가. 법의 연혁

친밀한 관계의 폭력을 규율하는 현행법으로 가정폭력처벌법과 스토킹처벌법을 들 수 있다. 이 중 「가정폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법(이하 가정폭력처벌법)」은 1998년 제정되었다. 가정폭력처벌법이 제정되기 이전에 가정폭력사안은 「형법」과 「폭력행위 등 처벌에 관한 법률」로 규율되었는데 부부관계라는 사적 영역의 특성상 국가의 개입이 자제되어야 한다는 생각이 퍼져 있어 적극적인 대응이 이루어지지 않았다. 그러나 사회적 이슈가 된 여러 사건을 거쳐, 가정폭력을 사회적 문제로 볼 필요가 있음을 인식하게 되었고 이는 가정폭력처벌법의 제정으로 이어졌다. 가정폭력처벌법은 제정된 후 20년 동안 여러 차례 개정을 거치면서 적극적인 대응을 구체화하는 양상으로 전개되었다.

「스토킹의 처벌 등에 관한 특례법(이하 스토킹처벌법)」은 1990년대 말부터 꾸준히 제정 필요성이 논의되었다. 2012년에 「경범죄처벌법」이 개정되어 ‘지속적 괴롭힘’이라는 행위가 경범죄의 유형에 추가되기는 하였으나 약 10만원의 과태료를 부과할 뿐이어서 행위의 중대성에 비해 제재가 지나치게 미약하다는 비판이 있었다. 이후 몇몇 스토킹

사건들이 이슈가 되면서 2021년 4월 스토킹처벌법이 제정되었다. 그런데 법 시행 이후에도 서울 중구 오피스텔 피해 여성 피살('21. 11.), 서울 송파구 빌라 신변보호 대상자 가족 피살('21. 12.), 서울 구로구 호프집 신변보호 피해 여성 피살('22. 2.), 신당역 스토킹 피해 역무원 피살('22. 9. 14.) 등의 사건이 끊이지 않았고, 스토킹처벌법이 스토킹 범죄를 예방하고 피해자들을 보호하는데 실효적이지 않다는 비판이 있었다. 이에 2023년 법이 개정되어 여러 조치가 추가로 도입되었다.

나. 법 규정의 유사성 분석

친밀한 관계의 폭력을 다루는 법의 가정폭력처벌법과 스토킹처벌법은 법체계와 구조에서 유사성이 있고, 제정과 개정을 거치며 이 같은 특징이 강화되고 있다.

1) 대응조치의 구조

가정폭력처벌법은 가정폭력에 대한 대응조치로 ① 사법경찰관의 응급조치(제5조): 폭력행위의 제지, 가정폭력행위자·피해자의 분리, 현행범인의 체포 등 ② 검사의 임시조치 청구(제8조)와 법원의 임시조치 부과(제29조): 피해자 또는 가정구성원의 주거 또는 점유하는 방실(房室)로부터의 퇴거 등 격리, 피해자 또는 가정구성원이나 그 주거·직장 등에서 100미터 이내의 접근 금지 등 ③ 법원의 임시조치 결정을 받을 수 없는 때 사법경찰관의 긴급임시조치(제8조의2)를 규정하고 있다.

스토킹처벌법의 대응조치도 유사한 체계를 갖고 있다. ① 사법경찰관의 응급조치(제3조): 스토킹행위의 제지, 스토킹행위자와 피해자등의 분리 및 범죄수사 등, ② 검사의 잠정조치 청구와 법원의 잠정조치 부과(제9조): 피해자에 대한 스토킹범죄 중단에 관한 서면 경고, 피해자 또는 그의 동거인, 가족이나 그 주거등으로부터 100미터 이내의 접근 금지 등 ③ 긴급을 요하는 경우 사법경찰관의 직권으로 긴급응급조치(제4조): 스토킹행위의 상대방등이나 그 주거 등으로부터 100미터 이내의 접근 금지 등을 규정하고 있다. 이처럼 가정폭력처벌법의 응급조치, 임시조치, 긴급임시조치와 스토킹처벌법의 응급조치, 잠정조치, 긴급응급조치는 명칭에 다소 차이가 있을 뿐 유사한 체계를 취하고 있다.

2) 신속한 초동대응의 도입

가정폭력처벌법은 초동대응 단계에서 여러 조치를 마련하고 있다. 경찰은 응급조치에서 폭력행위를 제지하거나 가정폭력행위자·피해자를 분리할 수 있으며, 2020년 개정으로 현행법 체포권한을 명시하여 초동대응을 강화 및 신속화하였다. 또한 경찰관의 긴급임시조치(제8조의2)에서 가정폭력범죄가 재발될 우려가 있고, 긴급을 요하여 법원의 임시조치 결정을 받을 수 없다면 사법경찰관이 임시조치를 취할 수 있도록 하여 임시적으로 피해자로부터 긴급격리 또는 접근금지조치를 할 수 있는 권한을 부여하고 있는 것도 이를 잘 보여준다. 스토킹처벌법에서는 응급조치(제3조)에서 스토킹행위의 제지, 향후 스토킹행위의 중단 통보뿐 아니라 범죄수사를 할 수 있는 권한을 규정하였고 스토킹행위가 지속적 또는 반복적으로 행하여질 우려가 있고 스토킹범죄의 예방을 위하여 긴급을 요하는 경우 주거 접근 금지, 전기통신을 이용한 접근 금지 등을 규정하고 있다. 이처럼 양 법에서는 범죄피해의 확산을 방지하기 위한 적극적인 초동대응을 규정하고 있다.

3) 조치불이행시 처벌부과

가정폭력처벌법에서는 임시조치의 실효성을 확보하기 위하여 2020년 임시조치불이행죄를 신설하여 정당한 사유 없이 제29조제1항제1호부터 제3호까지의 임시조치를 이행하지 아니한 가정폭력행위자에 대해 징역 또는 벌금을 부과할 수 있도록 규정하였다. 스토킹처벌법에서 잠정조치를 이행하지 아니한 사람은 제20조제2항에 따라 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처하도록 규정하고 있다. 2023년에는 법 개정으로 긴급응급조치의 불이행죄(제20조제3항)를 신설하였다. 이로써 긴급응급조치 불이행에 대한 제재는 종전 1천만원 이하의 과태료에서 1년 이하 징역 또는 1천만원 이하 벌금으로 상향되었다.

4) 피해자보호조치 규정

가정폭력처벌법에서 판사는 가정보호사건의 원활한 조사·심리 또는 피해자 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우 피해자가 직접 안전을 위해 임시조치를 청구할 수 있도록 규정하였으며 (제55조의2) 피해자에 대한 신변안전조치를 확대(제55조의2 제5항, 제

6항)하였다. 또한 심리의 결과 보호처분이 필요하다고 인정하는 경우 보호처분의 부과(제40조): 가정폭력행위자가 피해자 또는 가정구성원에게 접근하는 행위의 제한 등을 규정하고 있다. 스토킹처벌법에서도 피해자 또는 스토킹범죄 신고인 등에 대한 신변안전조치 신설(제17조의2 신설) 등 다양한 영역에서 피해자 보호를 위해 적극적인 조치를 규정하고 있다.

2. 데이트폭력처벌법에 관한 입법논의

친밀한 관계의 폭력에 관한 정책적 논의 중에는 데이트폭력에 관한 입법논의도 있다. 이는 데이트폭력에 관한 특례법을 제정하지는 것으로, 관련 법안이 발의되었고 활발히 논의되고 있으나,¹⁷⁾ 아직 구체적으로 입법 단계가 진행된 바는 없다. 이는 결정적인 장애물을 극복하기 어렵기 때문인데, 데이트 관계를 법으로 정의하는 문제이다. 데이트폭력에 관해 현재 논의되는 법안들은 ‘데이트 폭력’을 “서로 합의하여 교제관계에 있거나 있었던 사람 중 한 명 이상에 의하여 발생하는 신체적·정서적·경제적 폭력이나 그 위협” 또는 “교제관계에 있거나 있었던 사람이 상대방에게 그 의사에 반하여 생명·신체·재산에 위해를 가하는 행위”등으로 정의하고 있다.¹⁸⁾ 그런데 교제관계를 어떻게 정의할지, 다시 어려움에 봉착하게 된다.

그럼에도 데이트폭력처벌법을 제정하지는 입장의 주된 요지는 여성들이 교제 중인 상대방의 폭력을 감내하다가 큰 피해는 입는 경우가 많아 이를 억지할 수 있도록 가정폭력처벌법이나 스토킹처벌법처럼 강력한 조치가 필요하다는 것이다. 그런데 현재 교제 중에 있거나, 이전에 교제했던 이들 사이에서 일어난 폭력은 기존의 형법 규정을 적용할 수 있다. 만약 이 같은 행위가 상대방의 의사에 반(反)하여 정당한 이유 없이 상대방에게 불안감 또는 공포심을 일으키는 행위라면 스토킹처벌법을 적용할 수 있다. 데이트폭력처벌법을 제정하여 데이트폭력을 가중처벌해야 한다는 주장도 있지만, 데이트폭력처벌법이 없다고 해서 처벌 공백이 있는 것은 아니다. 그러나 이들에 가정폭력처벌법이나 스토킹

17) 2016년 박남춘 의원이 ‘데이트폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법안’을 대표발의하였고 20대 국회에서도 여러 건의 관련법안 발의가 있었다. 김구술, “데이트폭력범죄에 대한 입법적 대응방안”, 이화젠더법학, 제9권 제3호, 2017, 141-142면.

18) 김구술, 같은 논문, 150면.

킹처벌법상의 여러 조치나 제재를 적용할 수 없는 경우가 있다. 데이트폭력은 배우자간 폭력이 아니므로 가정폭력처벌법의 조치를 적용할 수 없고, 폭력이 스토킹의 범주에 해당하지 않는 행위라면 스토킹처벌법상의 조치를 활용할 수 없다. 이 경우 선제적 피해자 보호조치를 부과할 수 있는 제도적 근거가 없어 피해자의 안전이 위협받는다는 비판이 있다.¹⁹⁾

데이트폭력처벌법 발의안을 살펴보면 그 구조와 체계가 가정폭력처벌법이나 스토킹처벌법과 상당히 유사하다. 2023년 2월 법제사법위원회에 회부되었으나 계류 중인 법률안으로, 김미애 국민의힘 의원 등 15인이 발의한 ‘데이트폭력범죄의 처벌 및 피해자보호 등에 관한 법률안’²⁰⁾은 데이트폭력범죄를 알게 된 의료인, 구급 대원 등에 대한 신고의무 부과, 사법경찰관리의 응급조치 의무와 긴급응급조치, 데이트폭력행위자에 대한 잠정조치, 데이트폭력범죄에 대한 반의사불벌죄의 적용, 데이트폭력범죄 피해자에 대한 보호절차, 데이트폭력범죄의 처벌 및 절차에 관한 특례 등을 담고 있다. 이 같은 법이 도입된다면, ① 데이트폭력범죄의 경우에도 신고의무를 도입하고, ② 스토킹처벌법처럼 ‘반의사불벌죄’를 폐지하는 조항을 도입하여, 가해자가 피해자들로 하여금 처벌불원의 의사표시를 하도록 협박하거나 2차 가해를 가하지 못하도록 하는 장점을 누릴 수 있다. 이처럼 데이트폭력처벌법의 발의안들은 가정폭력처벌법, 스토킹처벌법과 유사한 구조와 조치로 피해자를 보호하고자 한다.

3. 법 유형 간 차이점

가정폭력처벌법과 스토킹처벌법, 입법 논의가 계속되는 데이트폭력처벌법은 친밀한 관계의 폭력을 포섭한다는 점에서 공통적인 경향성을 보이지만, 분명한 차이점이 있다. 가정폭력처벌법 제2조에 따라 가정폭력범죄가 규율하는 대상은 전·현 배우자에 한정되지 않고, 가정구성원에 해당하는 이들을 포함하고 있다. 데이트폭력 입법 논의에서 규율

19) 김효정, “젠더기반폭력으로서 친밀 관계 폭력의 특성과 쟁점: 현장의 지원 경험을 중심으로”, 한국여성학 제40권 제1호, 2024, 250면.

20) 1코노미뉴스, 2023.04.21., “여성1인가구위협 ‘데이트폭력처벌법’..처벌법은 요원”, <https://www.1conomynews.co.kr/news/articleView.html?idxno=23422> (최근 방문일 2023년 12월 22일).

하는 대상은 데이트 관계를 맺거나 맺었던 사람으로, 전형적인 친밀한 파트너 관계라고 할 수 있다. 이와 달리 스토킹처벌법의 행위주체는 스토킹범죄를 행하는 사람이고, 피해자는 스토킹범죄로 직접적인 피해를 입은 사람으로 규정하고 있다. 이에 따라 스토킹 행위를 한 이들과 이로 인해 피해를 당하는 이들이면 모두 규율의 대상이 되고, 가해자와 피해자의 관계에는 제한이 없다. 즉, 관계가 아니라 스토킹 행위 자체만을 대상으로 한다.

이들은 규율하는 행위유형에서도 차이가 있다. 가정폭력에서 다루는 폭력범죄의 범위는 형법, 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」, 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 등으로 새로운 구성요건을 창설한 것이 아니라 기존 법률로 규율할 수 있는 폭력을 예방하기 위한 조치 및 제재를 규율하는 것이다. 데이트폭력의 입법 논의도 이와 같이 기존에 없던 범죄 유형을 창설하는 것이 아니라 특정 관계를 전제로 하여 그들 사이에서 일어나는 폭력을 예방하고자 하는 반면, 스토킹처벌법에서 규율하는 “스토킹행위”란 상대방의 의사에 반(反)하여 정당한 이유 없이 상대방에게 불안감 또는 공포심을 일으키는 행위이다.²¹⁾ 이는 기존의 형사법 규정이 규율하던 행위가 아니라, 범죄유형과 구성요건을 창설하여 형법에서 규율하지 않던 영역으로 처벌범위를 확장한다.²²⁾ 이처럼 각각의 체계는 구조적으로 유사하지만, 대상 행위와 행위주체, 행위객체에서 차이가 있다.

이들 법은 범죄에 대한 대응의 양상에 있어서도 의미 있는 차이를 보인다. 입법 논의 중인 데이트폭력을 제외하고 분석해보자면, 가정폭력처벌법은 특정 관계인에게 신고의무(제4조)를 부여한다. 직무를 수행하면서 가정폭력범죄를 알게 된 경우에는 정당한 사유가 없으면 즉시 수사기관에 신고할 의무를 부여하여 사회가 적극적으로 개입할 것을

21) 스토킹처벌법 제2조에 따르면 이는 상대방 또는 그의 동거인, 가족(이하 ‘상대방등’)에게 접근하거나 따라다니거나 진로를 막아서는 행위, 상대방등의 주거, 직장, 학교, 그 밖에 일상적으로 생활하는 장소 또는 그 부근에서 기다리거나 지켜보는 행위, 상대방등에게 우편·전화·팩스 또는 「정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률」 제2조제1항제1호의 정보통신망을 이용하여 물건이나 글·말·부호·음향·그림·영상·화상을 도달하게 하거나 정보통신망을 이용하는 프로그램 또는 전화의 기능에 의하여 글·말·부호·음향·그림·영상·화상이 상대방등에게 나타나게 하는 행위 등의 행위를 포함한다.

22) 김잔디, “스토킹처벌법상 스토킹범죄의 성립요건 - ‘반복’의 판단기준을 중심으로 -”, 이화젠더법학, 제14권 제1호, 2022. 54-55면에 따르면 스토킹 행위 유형 중 접근, 기다리기, 연락하기 등은 일상적으로 행해지는 것으로, 전형적인 범죄의 행위태양과는 모습을 달리한다고 한다.

요청한다. 제9조에서 가정보호사건의 처리를 규정한 바도 중요하다. 검사는 가정폭력범죄로서 사건의 성질·동기 및 결과, 가정폭력행위자의 성행 등을 고려하여 보호처분을 하는 것이 적절하다고 인정하는 경우에는 가정보호사건으로 처리할 수 있다. 이 경우 검사는 피해자의 의사를 존중하여야 한다. 이에 따라 제40조에 보호처분을 규정하고 보호처분 등의 불이행죄(제63조)를 규정하고 있다. 이처럼 가정폭력처벌법은 가정폭력에 적극적으로 개입하면서도 원가정을 보호하고자 하며 그 결정에 피해자의 의사를 존중하고 있다. 스토킹처벌법에서는 피해자를 위한 조치를 보다 강화하는 양상을 보인다. 스토킹처벌법은 피해자 보호를 위한 제도적 장치를 보완·강화함으로써 스토킹범죄의 재발 및 강력범죄로의 확산을 방지하고 피해자를 실질적으로 보호하고자²³⁾ 여러 사항을 개정하였는데 이 중 반의사불벌죄 규정을 삭제한 것은 주요하다. 이는 피해자가 구체적으로 밝힌 의사에 반하여 공소를 제기할 수 없도록 하는 반의사불벌죄(제18조제3항) 규정을 폐지한 것이다. 또한 잠정조치의 유형에 스토킹행위자에 대한 위치추적 전자장치를 도입²⁴⁾한 점도 중요한 차이점이다.

IV. 친밀한 관계에서의 폭력을 다루는 법 정책에 대한 고찰과 비평

1. 현행 법체계의 공통적 경향에 대한 비판

친밀한 관계에서의 폭력에 대한 법적 규율을 살펴본 바와 같이 각 법에는 체계적인 유사성이 있으나 대상 영역과 규율하는 행위 유형에 차이가 있다. 그런데 해당 영역에서 진행되는 여러 법적 논의를 보면, 구조적 유사성만이 아니라 공통적인 경향성을 발견할 수 있다. 본고의 논의 목표도 이를 논의하고자 함에 있다. 앞서 살펴본 것처럼 가정폭력처벌법은 온전하게 친밀한 관계에서의 폭력을 규율하는 법이 아니고, 데이트폭력처벌법은 법의 제정에 대한 합의에 이르지 못했으며 스토킹처벌법은 친밀한 관계를 전제로 하

23) 2023. 7. 11. 제정, 2024. 1. 12. 시행 스토킹처벌법의 개정이유.

24) 스토킹처벌법 제9조제1항제3호의2, 같은 조 제3항·제4항 신설.

는 것이 아니라 그러한 관계 사이에서 발생하는 범죄 유형 중 일부를 규율한다. 그럼에도 이들 유형을 묶어 살피는 이유는, 친밀한 관계에서의 폭력과 관련한 이들 영역이 친밀한 관계에서의 피해자 보호라는 목적에 집중해 다양한 조치를 도입했거나 도입하려는 중이기 때문이다. 이 같은 조치 모두를 친밀한 관계에서의 폭력 관점에서 해석할 수 있는 것은 아니지만 정책의 공통적 배경과 목표는 친밀한 관계에서의 피해자들이 스스로를 보호하기 어렵다는 문제의식을 기반으로 하고 있다. 이에 피해확산을 방지하고 범죄를 예방할 필요에 주력하여 강력한 조치를 피하고 있음을 후술할 조치들이 잘 보여주고 있다. 그런데 이들 정책이 피해자 보호를 제대로 실현하면서 법적 정당성을 갖추었는지에 대한 깊이 있는 고려가 뒷받침되고 있지 않다는 점을 확인할 수 있었다. 이 같은 범 유형의 공통적 경향성이 피해자 보호에 방점을 두되 다음과 같이 정당성 문제가 있음을 비판적으로 고찰한다.

가. 엄벌주의적 경향성의 강화

친밀한 관계의 폭력을 규율하는 법 유형이 도입하는 조치는 대체로 엄벌주의적 경향이 강하게 드러난다. 이는 가치관의 변화, 사회 문화의 변화에 따른 사회의 요구를 법이 수용하면서 나타난 변화이다. 형사법은 최후수단성 원칙이라는 중대하고도 근본적인 이념을 추구해야 하나, 형법이 적극적인 역할을 수행할 필요가 있는 상황에서는 전통적인 굴레에만 갇혀있을 수는 없을 것이며, 실효적인 정책을 추구하는 것은 형법의 주요한 임무이다. 그런데 최근 형법 학계에서 진행되는 주류적 논의 중 하나는 엄벌주의 경향성이 강화되고 있는 형법 흐름에 대한 우려이다. 법은 범죄자의 의욕을 억지하여 범죄피해를 방지하고 피해자를 보호하는데 실효적이어야 하는 바, 제재를 강화할 필요가 있다. 그러나 이러한 목적 아래 형법의 기본적인 이념과 원칙들을 도외시하는 것은 아닌지 비판적으로 고찰해야 한다는 목소리가 높아지고 있다. 대중 인기에 영합하는 정책, 이른바 포퓰리즘이 형법을 과잉으로 만든다는 비판도 제기된다. 현행법상의 여러 정책을 고찰할 때, 이들이 실효적이면서도 법적으로 정당화될 수 있는 정책이라기보다 대중의 요구를 성급히 수용하고 정당성에 대한 충분한 고려 없이 도입된 정책이 아닌지 반성적으로 검토해볼 필요가 있다.

나. 관계의 특성을 도외시하는 정책 추구

친밀한 관계에서의 폭력을 규율하는 법 정책의 또 다른 문제는 공통적인 경향성이 강화되면서 각 법률의 내용상 유사성 또한 높아지고 있다는 것이다. 피해자 보호를 위해 필요한 조치들이 도입되는 만큼, 그 조치의 내용이 공통적인 것은 당연하다. 그러나 법은 대상영역의 차이와 특수성을 반영하는 만큼 일률적인 방향을 좇는 것만이 올바른 방향은 아니다. 특히 친밀한 관계의 폭력을 다루는 법들은 관계의 특성을 반영해야 하는데, 그 같은 차이를 진지하게 고려하지 않고 모두 엄격한 조치만을 추구하기만 한다면 법적 정당성은 약화된다. 예컨대 후술할 반의사불벌죄는 피해자에게 처벌불원의 의사를 밝히라며 2차적 가해를 하게 하는 문제를 야기한다는 지적을 받는다. 스토킹처벌법에서 이 조항을 삭제했는데 가정폭력처벌법에서도 이를 폐지해야 한다는 주장이 제기되고 있다. 가정폭력에서의 보호사건 처리²⁵⁾를 삭제해야 한다는 논의도 마찬가지이다. 친밀한 관계에서의 폭력을 다루는 법이 일률적이어야 하는가?

다음에서 논의하는 쟁점들은 논의를 거쳐 법으로 개정되었거나 개정 논의를 앞두고 있는 정책들이다. 이를 유형별로 살펴보면 각 정책별 성격을 분석하고, 본 논의에서 제기하는 비판점을 바탕으로 그 정당성을 검토하고자 한다.

2. 정책별 분석과 평가

가. 분리 조치의 강화

범죄를 예방하려면 가해자와 피해자의 신속한 분리가 선행되어야 한다는 것은 오랫동안 논의해온 중요한 쟁점이다. 친밀한 관계의 폭력 범죄를 예방하기 위해 가해자를 감시하거나 제재를 가하는 조치도 중요하지만, 초기에 가해자와 피해자를 신속히 분리하는

25) 가정폭력처벌법 제9조(가정보호사건의 처리)는 ① 검사는 가정폭력범죄로서 사건의 성질·동기 및 결과, 가정폭력행위자의 성행 등을 고려하여 이 법에 따른 보호처분을 하는 것이 적절하다고 인정하는 경우에는 가정보호사건으로 처리할 수 있다. 이 경우 검사는 피해자의 의사를 존중하여야 한다고 규정하고 있다. 이 조항에 따라 법원은 가정폭력 가해자에게 보호처분을 부과할 수 있는데, 이 때문에 엄벌을 부과하여 가정폭력을 예방해야 할 사건에 보호처분이라는 약한 제재를 부과하게 된다는 비판도 있다.

방안이 실효성 측면에서 큰 의의를 갖기 때문이다. 가정폭력처벌법은 현행법상 다양한 분리조치가 여러 단계에서 규정되고 있는데, ① 초동조치단계에서 가정폭력처벌법 제5조의1: 가정폭력행위자·피해자의 분리, 1의2: 「형사소송법」 제212조에 따른 현행범인의 체포 등 범죄수사, 제5조의2: 피해자를 가정폭력 관련 상담소 또는 보호시설로 인도하는 조치가 있고, ② 검찰의 임시조치 청구 단계에서 1. 피해자 또는 가정구성원의 주거 또는 점유하는 방실(房室)로부터의 퇴거 등 격리, 2. 피해자 또는 가정구성원이나 그 주거·직장 등에서 100미터 이내의 접근 금지, 3. 피해자 또는 가정구성원에 대한 「전기통신기본법」 제2조제1호의 전기통신을 이용한 접근 금지 등을 규정하고 있다. 스토킹처벌법의 응급조치, 잠정조치에서도 이와 같은 내용의 분리조치를 규정하고 있다.

이 같은 조치들은 크게 가해자와 피해자의 거리를 유지하거나, 피해자를 안전한 시설로 인도하거나, 가해자를 체포하는 등의 조치로 유형화해볼 수 있다. 그 성격을 다시 살펴보면 피해자를 적극적으로 보호하거나 가해자에게 특정한 의무를 부과하거나 금지를 가하는 방식 중에서 어느 쪽에 치중하느냐를 기준으로 구분할 수 있을 것이다. 예컨대 독일은 “가해자는 떠나고 피해자는 남는다”는 모토를 실천하고자 하여, 가정폭력이 발생한 경우 가해자를 적극적으로 분리하고 있다.²⁶⁾ 이는 가해자에게 강력한 의무를 부과하여 가해자와 피해자를 분리하는 방식이다. 이와 달리 피해자 보호에 초점을 둔 분리조치로는 가정폭력처벌법과 스토킹처벌법에 규정되어 있는 피해자의 신변안전조치²⁷⁾를 들 수 있다. 특정시설에서의 보호, 신변경호, 참고인 또는 증인으로 출석·귀가 시 동행 등을 포함하고 있다.

친밀한 관계에서의 폭력 유형의 특성상, 가해자와 피해자의 분리조치를 강화하는 정책은 실효적이고 타당하다. 가해자-피해자의 분리조치는 가해자에 대한 여타 제재보다 범죄예방을 우선순위에 두면서, 피해자 보호를 우선시한다. 또한 제재적 성격이 강하지 않다는 점에서 법적 정당화 문제에서 보다 자유롭기 때문에 정책의 확대를 고려해볼 필요가 있다. 이러한 관점에서 볼 때 현행법상 초동단계에서 경찰의 분리조치, 피해자에 대한 접근금지 등을 다양한 조치를 규정한 것은 실효적이고 타당하다. 이에 바탕을 두고

26) 윤정숙 외 5인, 같은 보고서, 554-555면.

27) 가정폭력처벌법 제55조의2 제5항, 스토킹처벌법 제17조의2항에서 피해자의 신변안전조치를 규정하고 있다.

논해볼 정책적 쟁점 중 하나는 가정폭력의 경우 의무적 체포·분리에 관한 논의이다. 미국의 경우 1960년대 매맞는 여성 증후군(Battered Women Syndrome)를 논의하며 가정폭력을 본격적으로 문제로 인식하기 시작하였다.²⁸⁾ 뒤이어 경찰의 대응 방법이 가정폭력을 줄이는데 미친 효과를 실험한 미네아폴리스 가정폭력 실험연구(Minneapolis Domestic Violence Experiment, 1981년~1982년)에서 ‘체포·구속이 다른 처우보다 가정폭력행위자의 위반행위를 유의미하게 억제한다’고 발표²⁹⁾(1984년)한 바가 의무체포제도의 기폭제가 되었다³⁰⁾. 이는 배우자를 향해 뺨을 때리는 정도의 폭력이 발생했을 때 피해자 진술만으로도 가정폭력이 있었다는 상당한 근거를 인정해 경찰이 가해자를 체포해야 한다는 것이다.³¹⁾ 이러한 논의를 거쳐 1994년 여성폭력방지법 가정폭력 가해자에 대한 의무적 체포제도가 도입되어 23개주에서 이를 채택하기에 이르렀다.³²⁾

물론 우리 현행법상으로도 경찰의 초동대응조치에 현행법 체포를 규정하도록 개정되었음에도 의무적 체포를 도입해야할 실익이 있는지 의구심이 있을 수 있다. 그런데 대법원은 현행법 체포의 요건으로 범죄의 가벌성, 현행성, 시간적 접착성, 명백성 외에도 체포의 필요성 즉 도망 또는 증거인멸의 염려가 있어야 한다고 판시하고 있다.³³⁾ 가정폭력으로 출동하였을 경우 현행범으로 체포하려면 이 같은 요건을 모두 충족시켜야 하는데, 가정폭력에는 반의사불벌죄가 규정되어 있기 때문에 경찰관은 신고 현장에서 피해자의 의사에 반하여 체포하는 것을 꺼려한다.³⁴⁾

미국에서는 가정폭력 가해자에 대한 영장 없는 체포를 규율하는 법 규정을 세 가지 유형으로 분류하고 있는데, 체포 여부의 결정에 관한 권한에 따라 의무적 체포(Mandatory Arrest), 우선적 체포(Preferred Arrest), 재량적 체포(Discretionary Arrest)를 규정하고 있다. 의무적 체포(Mandatory Arrest)는 가정폭력 가해자를 체포하

28) 송현진, “미국의 가정폭력범죄 의무체포제도에 대한 연구: 경찰 집행 매뉴얼과 제도 문제점을 중심으로”, 치안정책연구, 제34권 제3호, 2020, 171면.

29) Sherman, L., R. A. Berk(1984), The Minneapolis Domestic Violence Experiment, Police Foundation를 인용한 김구슬, “데이트폭력범죄에 대한 입법적 대응방안”, 이화젠더법학, 제9권 제3호, 2017, 147면에서 재인용함.

30) 송현진, 같은 논문, 171-172면.

31) 윤정숙 외 5인, 같은 보고서, 499면.

32) 송현진, 같은 논문, 174-175면.

33) 대법원 2011. 5. 26. 선고 2011도3682 판결.

34) 송현진, 같은 논문, 168면.

는 경찰에게 재량권이 없고 가해자를 의무적으로 체포하도록 규정하고 있다. 우선적 체포(Preferred Arrest)는 의무적 체포는 아니지만, 체포를 우선시하도록 규정한 것이다. 의무적 체포제도는 경찰이 가정 폭력이 발생하였다고 믿을 만한 상당한 이유가 있으면 현장에서 즉시 행위자를 체포할 의무를 부여하기 때문에³⁵⁾ 경찰의 현장에서 대응력을 높이며 피해자 보호를 강화할 조치가 될 수 있다. 물론 의무체포제도는 헌법에서 규정하는 거주이전의 자유를 침해한다는 문제³⁶⁾, 피체포자의 인권 침해 문제와 더불어, 오히려 가정폭력의 신고를 줄일 가능성이 있다는 점에서 많은 문제를 야기할 수 있다.³⁷⁾ 생각건대, 가정폭력 가해자를 의무적으로 체포하는 제도는 가해자와 피해자를 신속히 분리하고 더 큰 피해로의 확산을 사전에 예방할 수 있을 것이나, 이는 피체포자 인권을 침해하거나, 오히려 가정폭력의 신고율을 감소시키고 중한 보복폭력을 야기할 수 있다는 부작용도 있다.³⁸⁾

그럼에도 우선적 체포제도는 여타 제재와 비교할 때 법적 정당성 측면에서 의미있는 제도이다. 후술할 정책으로 가해자를 감호위탁하는 등의 제재와 비교하면 인신구속에 대한 제재적 측면이 완화된다는 점에서 의의가 있다. 이는 실효성 측면에서도 효과적이다. 여러 사정을 고려할 때 중대한 피해를 야기할 우려가 있다면 우선적으로 가해자를 체포해야 초기에 가정폭력을 예방할 수 있을 것이다. 이 같은 맥락에서 가정폭력에 있어 체포 우선주의를 명문화할 것을 규정하는 발의안도 있었다.³⁹⁾ 다만 가해자들이 분리조치 이후 앙심을 품고 보복하는 경우가 많다는 점을 고려할 때⁴⁰⁾ 피해자에 대한 보호조치도 고려해야 할 부분이다.

이 같은 관점을 고려하자면, 분리 조치에 있어 더욱 중요한 것은 피해자에 대한 지원 강화일 것이다. 특히 가정폭력을 벗어나려면 그 첫 관문은 안전하고 적절한 거소를 찾는 것이다. 특히 저소득층 가정에서는 가정폭력 피해자들이 경제적 여력이 없어 가정폭력을

35) 김구슬, 같은 논문, 47면.

36) 윤정숙 외 5인, 같은 보고서, 576면.

37) 송현진, 같은 논문, 186-187면.

38) 송현진, 같은 논문, 169면.

39) 메디컬투데이, 2020.06.16., “‘가정폭력 가해자에 보호처분 및 상담조건부 기소유예 폐지’ 추진”, <https://www.mdtoday.co.kr/mdtoday/index.html?no=390139> (최근 방문일 2023년 12월 22일).

40) 주간조선, 2022.09.30., “스토킹범 분리조치 후 78% 피해자 찾아가 보복”, <https://weekly.chosun.com/news/articleView.html?idxno=22363> (최근 방문일 2023년 12월 22일).

감내하는 경우가 더 많다. 미국에서는 법으로 피해자의 거주지를 원조하는 규정을 마련하였다. 2003년 의회가 피해여성을 위한 거주지 지원기금을 마련해 피해여성들이 영구적인 거주지로 이사할 수 있었고, 2005년과 2013년 재승인된 여성폭력방지법에서는 피해자들이 잠재적인 폭력위험으로부터 벗어나 다른 지역으로 이주할 수 있도록 원조하는 규정을 담았다.⁴¹⁾ 이처럼 해외에서는 피해자의 이주를 적극 지원하는 제도가 있다. 우리 현행법에서도 특정범죄신고자 등 보호법에서 신변보호조치 등이 규정되어 있고, 피해자를 특정시설에 보호하거나 피해자의 주거보호, 신변경호 등을 지원할 수 있도록 규정하고 있다. 그러나 피해자지원기관 종사자들이 보호시설이 매우 열악함을 공통적으로 지적하고 있는 현실⁴²⁾과 스토킹처벌법상 규정에도 불구하고 스토킹지원시설을 갖춘 지자체가 매우 적다는 점⁴³⁾을 고려할 때 현행법 규정보다 피해자 보호제도가 강화될 필요가 있다.

물론 이 같은 분리 정책은 많은 자원을 필요로 하고 행정적 부담이 크기 때문에 무조건적인 확대를 요청하기는 어렵지만, 사건이 발생한 사후에 가해자를 엄중히 처벌하는 것만으로는 한계가 있다. 중요한 것은 더 큰 피해가 발생하기 전에 이를 차단하는 것이다. 정당성 관점에서 보건대 가해자를 체포하는 방식의 분리조치는 가해자에 대한 직접적 제재보다 제재적 성격이 완화되므로 이를 강화하는 것은 타당하고, 피해자 지원 위주의 분리조치 또한 정당성이 있어 확장할 필요가 있다.

나. 엄벌주의를 바탕으로 한 예방

1) 반의사불벌죄의 폐지

2023년 스토킹처벌법 개정안에서 반의사불벌죄 조항을 폐지한 이래, 가정폭력처벌법에서도 반의사불벌죄를 폐지해야 한다는 목소리가 높다. 2022년 개정된 발의안에서도 이와 같은 내용이 담겼는데,⁴⁴⁾ 가정 내에서 가해자가 피해자를 회유하거나 협박하여 처

41) 홍영오·연성진·주승희, 같은 보고서, 354면.

42) 윤정숙 외 5인, 같은 보고서, 295면.

43) 프레시안 뉴스, 2023.09.15., “‘스토킹 파격조치’ 장담한 한동훈, 이후 1년 ‘대체 뭐가 바뀌었나’”, https://www.pressian.com/pages/articles/2023091418011507918?utm_source=naver&utm_medium=search, (최근 방문일 2023년 12월 22일).

법불원의 의사를 표시하도록 종용하는 일이 잦고, 피해자와 가해자가 한 공간에 머무르는 경우가 많아 재범 위험성이 높기 때문이다. 특히 가족의 경우 금전적 문제나 양육 등 현실적인 이유로 피해자가 가해자의 처벌을 적극적으로 주장하기 어렵다보니, 피해자가 처벌을 원치 않더라도 이를 처벌하여 가정 내에서 발생할 수 있는 폭력을 억지해야 한다는 주장이 있다.

그런데 친밀한 관계를 다루는 법체계의 구조와 내용이 유사해진다고 해서 관계의 특성과 차이를 무시하고 일률적으로 엄벌주의를 규율할 수는 없다. 생각건대, 친밀한 관계 중에서도 가정 내의 관계는 개인의 선택권을 보장해야 할 영역임에 틀림없다. 물론 가정 폭력으로 인한 피해는 중요한 사회적 문제이기에 국가가 적극적으로 개입하여야 한다는 데 사회적 합의가 모이고 있다. 그럼에도 이러한 문제에서는 관계의 특성을 고려하여야 하며 국가는 가정 내의 피해자가 원가정이 깨지지 않기를 위하여 처벌을 불원하는 의사를 가지고 있다면 이를 존중할 필요가 있다. 친밀한 관계에서의 폭력 문제에서 반의사불벌죄의 폐지 조항 도입은 일률적으로 규정할 것이 아니라 신중하게 접근할 문제이며 가정폭력의 경우 도입을 자제할 필요가 있다.

2) 조치위반의 형사화

가정폭력처벌법에서 가정폭력에 대응하는 조치로 응급조치, 긴급임시조치, 임시조치, 보호처분이 있고, 스토킹처벌법에서는 대응 조치로 응급조치, 긴급응급조치, 잠정조치를 규정하고 있다. 이 중에서 실질적으로 가해자에게 범죄예방을 위한 조치를 따를 의무를 부과하는 조치는 가정폭력처벌법상 임시조치, 보호처분과 스토킹처벌법상 긴급응급조치, 잠정조치이다. 이들 법에서는 이와 같은 조치를 불이행할 시, 다시 말하여 가해자에게 부과된 의무를 따르지 않을 시 형벌로 제재를 가하여 그 이행을 강제하고 있다. 가정폭력처벌법의 보호처분을 제외하면, 판결 이전의 중간단계에 가해자에 대한 조치를 규정하고 이행할 의무를 부과하는 것이다.

가정폭력처벌법에는 보호처분의 불이행죄만 규정되어 있었고 이에 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금 또는 구류를 정하였는데, 2020년 법 개정으로 임시조치불이

44) 신아일보, 2022.10.01., “김영주 국무부외장, 스토킹·가정폭력 범죄 반의사불벌죄 폐지 추진”, <https://www.shinailbo.co.kr/news/articleView.html?idxno=1605590> (2023년 12월 22일).

행위를 도입하여 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금 또는 구류를 규정하였다. 스토킹처벌법에서는 잠정조치불이행죄를 규정하고 있었는데, 2023년 법 개정으로 잠정조치 위반시 2년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다고 규정하여 법정형을 상향하였다. 또한 2023년 개정으로 긴급임시조치의 위반도 형사화되면서, 스토킹행위의 상대방등이나 그 주거등으로부터 100미터 이내의 접근 금지, 스토킹행위의 상대방등에 대한 「전기통신기본법」 제2조제1호의 전기통신을 이용한 접근 금지 등을 위반할 시 형벌로 규율할 수 있게 되었다. 이전에는 이 같은 조치들의 위반에 대한 제재가 지나치게 경미하여 실효성이 떨어진다는 지적이 있었다. 긴급응급조치나 긴급임시조치처럼 경찰의 초동대응 단계에서 취할 수 있는 조치는 신속성에서 큰 장점이 있는데, 이를 불이행했을 경우 경미한 제재만 부과하면 즉각적이고 효과적인 제재수단으로 기능하기 어렵다는 것이었다.⁴⁵⁾

이러한 논의를 거쳐 법이 각각 개정되면서 가해자에게 구체적인 의무를 부과하지 않는 응급조치를 제외한 모든 조치에 형벌이 부과되었다. 이 같은 논의와 관련한 쟁점은 이러한 경향성을 현재보다 강화해야 한다는 논의이다. 물론 친밀한 관계의 폭력이 종종 중대한 피해로 발전한다는 점과 그 심각성을 고려하면, 판결 이전 중간단계의 조치들의 위반에 형벌을 부과하는 것은 실효성과 정당성 측면에서 타당하다. 때문에 이러한 경향을 보다 강화해야 한다는 의견도 제기되고 있는데⁴⁶⁾, 이 같은 조치들이 중간단계의 조치라는 점을 고려할 때 가정폭력이 유죄로 확정되었을 시의 법정형 및 양형과도 비교해볼 필요가 있다. 긴급응급조치와 임시조치, 잠정조치 위반, 보호처분의 위반은 그 중대성이 다르기 때문에 위계가 필요하고, 실제로 법정형을 살펴보면 후자로 갈수록 높아지는 경향을 보인다. 그런데 친밀한 관계의 폭력에 관한 법이 그 대상영역을 일률적인 기준으로 다룰 필요는 없으며 관계 특성에 따른 차이, 위반 조치의 경중, 체계정합성 등을 고려해 신중히 도입해야 한다.

45) 윤정숙 외 5인, 같은 보고서. 613-614면.

46) NEWSIS, 2023.11.13., “흉기 등 휴대 스토킹범죄 최대 징역 5년까지 권고”, https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231113_0002518938&cID=10201&pID=10200 (최근 방문일 2023년 12월 22일). 이러한 맥락에서 양형위원회는 스토킹범죄의 조치 위반에 대한 양형에서 원칙적으로 벌금형을 배제하는 등 엄격한 기준을 적용하기로 하였다.

다. 범죄 예방 목적 하에 형벌 이외의 제재 강화

1) 잠정조치 유형에 전자장치부착 추가

2023년 개정된 스토킹처벌법 스토킹행위자에 대한 잠정조치의 유형에 위치추적 전자장치를 추가함으로써 스토킹행위자의 위치추적을 가능케 하였다. 본래 위치추적 전자장치는 보안처분의 한 유형으로 2008년 성범죄자를 대상으로 도입된 이래 대상범죄가 계속적으로 확대되어 왔다. 그런데 위치추적 전자장치가 스토킹 행위에 잠정조치 유형에 추가된 바는 보안처분으로서 위치추적 전자장치의 본래적인 법적 성격에 부합되지 않는 면이 있어, 그 성격과 타당성을 논의해볼 필요가 있다.

한국에서 2008년에 전자장치 부착제도를 도입할 때부터 해당 제도는 집행종료 이후에 특정범죄자, 주로 고위험 성폭력 범죄자들의 재범을 방지하려는 목적을 강하게 갖고 있었다.⁴⁷⁾ 해당 법에서는 (1) 징역형 종료 후 (2) 가석방·가중료·치료위탁시 (3) 형의 집행유예시에 전자장치를 부착할 수 있도록 규정하고 있었는데, 2020년에 전자장치부착법을 개정하여 재판 전단계에서도 전자감독을 적용할 수 있도록 하는 제도로 전자감독 조건부 보석제도가 도입되면서(「전자장치부착법」 제31조의2) 재판 전후 단계를 막론하고 형사사법절차 전반에서 전자감독제도가 활용되고 있다. 이처럼 위치추적 전자장치는 시행이 확대되었고, 단기구금의 대체형벌로도 논의되는 만큼, 위치추적 전자장치가 국내 형사사법체계의 정문과 후문을 모두 아우르게 되었다고 평가기도 한다.⁴⁸⁾

2023년 개정된 스토킹처벌법은 스토킹범죄의 원활한 조사·심리 또는 피해자 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우 부과하는 잠정조치에 위치추적 전자장치 부착을 추가하였다. 이는 2024년부터 본격적으로 시행될 것이며 점차 확대될 것으로 보인다. 그런데 이 같은 조치는 전자감독 장치의 본래적인 성격이 보안처분이라는 점을 고려하면 문제가 있다. 본래 보안처분은 과거 범죄에 대한 응보인 형벌과 달리, 행위자의 장래 위험성을 예방하는데 존재근거가 있다.⁴⁹⁾ 이 같은 개념은 형 집행 종료 후의 단계에 부합하는 개념이다. 물론 보안처분의 존재근거가 재범의 방지이며 범죄자의 재범 위험성을 평가하여

47) 황태정, “전자감독제도의 비교법적 검토와 시사점”, 아주법학 제11권 제1호, 2017, 168면.

48) 김남규 외 4인, “스토킹 행위자 위치추적 전자장치 부착제도의 도입 쟁점과 과제”, 형사정책연구 제34권 제2호, 2023, 94면.

49) 배종대·홍영기, 「형사정책」, 홍문사, 2019, 466면.

부과하는 것이라고 한다면, 위치추적 전자장치는 이미 보안처분의 본래적인 성격에서 벗어난 제도이다. 그리고 이러한 점에서 다른 보안처분과도 차별성을 갖는다.⁵⁰⁾ 이 같은 변화는 위치추적 전자장치법 제1조의 목적 변화에서도 드러난다. 위치추적전자장치법 제1조의 전문은 원래 “이 법은 특정범죄를 저지른 사람의 재범방지를 위하여 형기를 마친 뒤에 보호관찰 등을 통하여 지도하고 보살피며 도움으로써”로 규정하고 있었으나 2020년에 이를 개정하면서 ‘재범의 방지’라는 문구를 삭제하였다. 이미 이 같은 제도적 변화가 있었던 이상, 위치추적 전자장치를 형 집행 종료 이후의 보안처분에 한정해 생각할 수 없다.

그렇다고 하더라도 스토킹법상 잠정조치에 규정된 위치추적 전자장치는 본래적 성격을 지나치게 벗어났다고 볼 수 있다. 스토킹법상 잠정조치는 법원의 결정으로 부과되는 하나, 잠정조치는 ‘스토킹범죄의 원활한 조사·심리 또는 피해자 보호를 위하여 필요하다고 인정하는 경우에 부과되는 것’으로 형사사범의 특정단계에 이를 것을 요하지 않는다. 전자장치부착법에서는 스토킹 범죄에 대해 부착명령을 청구할 수 있는 경우로, 1. 스토킹범죄로 징역형의 실형을 선고받은 사람이 그 집행을 종료한 후 또는 집행이 면제된 후 10년 이내에 다시 스토킹범죄를 저지른 때, 2. 스토킹범죄로 이 법에 따른 전자장치를 부착하였던 전력이 있는 사람이 다시 스토킹범죄를 저지른 때, 3. 스토킹범죄를 2회 이상 범하여(유죄의 확정판결을 받은 경우를 포함한다) 그 습벽이 인정된 때로 규정하고 있는데, 잠정조치의 성격상 유죄의 확정판결이 있어야만 조치를 부과할 수 있는 것은 아니다. 수사·재판·집행 등 형사사법절차 중에 전자장치 부착을 명할 수 있도록 법을 개정하였다고는 하나, 잠정조치와 같은 초동 대응단계에서 전자장치를 부착하게 규정한 것은 지나치게 과도한 제재가 될 수 있다. 부과의 정당성 면에서 심도 있는 고민이 필요한 부분이다.

물론 보안처분은 형벌과 달리 그 개념이 명확하지 않고 다의적이며 역사가 길지 않아 개념과 내용이 계속적으로 변하고 있다. 따라서 보안처분이 일반적으로 재범 방지라는 목적에 그 존재 근거가 있다고는 하지만, 사회 방위의 목적을 달성하기 위하여 위치추적 전자장치의 적용 단계를 형 집행 종료 이전으로 확장한다고 하더라도 본래적 성격과 어

50) 김지선 외 4인, 「중형주의 형사제재의 실효성에 관한 평가연구(Ⅱ) - 전자감독제도의 실효성 평가연구 -」, 형사·법무정책연구원, 2021, 30면.

곳나 부당한 것이라고는 할 수 없다. 그럼에도, 이 같은 평가는 처분을 부과하는 시기에 따라 달라질 수 있다. 정당성 측면에서 고찰해보자면, 잠정조치는 범죄의 성부를 사법적으로 논하여 유죄를 인정하기 전, 중간단계적인 조치이고 이 단계에서 전자장치를 부착하는 것은 전자장치 부착을 조건부로 보석을 허용하는 것보다 사법적으로 훨씬 이른 단계에서 이를 허용하는 것이라는 점에서 문제가 있다. 물론 기존 대안의 실효성 부족을 극복하려고 하는 목적에서는 타당하며, 현행 제도를 경찰이 판단하는 긴급응급조치가 아니라 법관의 판단을 필요로 하는 잠정조치에 포함하여 운용한다는 점⁵¹⁾에서 법적 정당성의 문제가 완화되는 면이 있다. 또한 전자장치를 부착하는 경우에도 잠정조치의 사유를 판단하기 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 검사, 스톱킹행위자, 피해자, 기타 참고인으로부터 의견을 들을 수 있다고 규정을 신설하였고, 법원이 잠정조치를 결정한 경우에는 검사와 피해자 또는 그의 동거인, 가족, 그 법정대리인에게 통지하여야 한다고 규정⁵²⁾을 신설하여 정당성 문제를 극복하려는 시도와 노력이 엿보인다.

그러나 전자장치의 본질을 고려할 때 이는 법적 또는 운용상의 혼란을 초래할 수 있다. 전자장치와 같은 보안처분은 재범의 관리와 보호에 치중하고 경찰력은 범죄에의 초기 대응과 피해자보호에 치중하는데, 이 같은 제도 때문에 각 역할이 모호해질 것이다. 또한 전자장치 부착명령을 법원이 하고, 위치추적과 접근금지 명령 위반여부의 감시는 법무부의 위치추적 관제센터가 담당할 것이며, 범죄대응과 예방은 경찰이 담당하는 구조로 운용될 것인데, 각 기관간의 이해관계가 상이하여 상호 협력에 상당한 어려움이 있을 것도 예상된다는 지적이 있었다.⁵³⁾ 이런 우려를 극복하더라도 현행 제도가 정당성을 충족하는지 명확하지 않다는 비판과 마주할 수 있다. 보안처분은 형벌의 부차적인 수단인긴 하나, 형벌을 지배하는 근본원리를 따라야 한다. 책임원칙 안에 갇든 비례성 사고에 따라 발생한 불법행위와 엄격하게 비례해야 하고 그러한 비례성 원칙을 수행하려면 불확실한 예측에 기대어 보안처분을 부과할 때 정형화된 법치국가적 장치로 제한을 부과해야 한다. 그와 같은 제한이 실현되는 방식은 범죄위험성의 예측이라는 요건이다. 과거의 원인행위를 토대로 하여 범죄행위에 대한 위험성을 예측하고, 이 같은 범죄예측을 넘어서

51) 김남규·박다윤·노희주·김도선·김연수, “스토킹 행위자 위치추적 전자장치 부착제도의 도입 쟁점과 과제”, 형사정책연구 제34권 제2호, 2023, 111면.

52) 전자장치 부착 등에 관한 법률 제31조의6항.

53) 김남규·박다윤·노희주·김도선·김연수, 같은 논문, 111면.

는 정도의 보안처분을 부과하지 않는 것이어야 하는데,⁵⁴⁾ 재범위험성을 제대로 판단할 수 없는 단계에서 위치추적 전자장치와 같은 강력한 수단을 부과하는 것은 비례성을 위배하는 것일 수도 있다. 이는 법원의 판단을 거쳐 잠정조치로서 이를 부과하더라도 마찬가지이다. 비례성 원칙의 가장 핵심적인 이념은 최소침해의 원칙에 있는데, 현재와 같은 방식으로는 이를 실현할 수 있을지 의문이 있다. 전자감독을 부착한다고 해서 범죄자가 범죄를 범할 가능성을 완전히 차단할 수 있는 것은 아님을 보여주는 실제사례들을 볼 때 이 같은 의문은 공고해진다. 예외적으로만 전자장치를 부착할 수 있도록 대상자 요건을 세분화한다면 이 같은 문제가 어느 정도 완화될 수 있겠으나 시기·기간 등을 규정하지 않으면 위험적 성격을 온전히 제거하기는 어려울 것이다.

2) 가정폭력처벌법상 감호위탁처분

최근 가정폭력처벌법의 보호처분 단계에서 부과하는 감호위탁처분이 2023년 법 개정으로 현실적으로 적용가능하게 바뀐 부분 역시 주목할 만하다. 본래 감호위탁처분은 보호감호의 한 종류로 구 사회보호법이 규정하고 있었다. 구 사회보호법에서는 보호감호를 규정하면서 실행을 선고받고 형기를 마친 이를 교정시설이 아닌 보호감호시설에 수용하여 감호·교화하고, 사회복귀에 필요한 직업훈련과 근로를 과할 수 있다고 하였다. 또한 보호감호시설의 장은 직업훈련·근로·치료, 기타 감호·교화에 필요하다고 인정되는 때에 적당한 기관에 피보호감호자의 감호 등을 위탁할 수 있다고 규정하고 있었다. 그러나 범죄인을 교정시설에 수용하지 않더라도 보호감호시설에 수용하는 것 또한 이중처벌·과잉처벌에 해당할 수 있어 인권을 침해할 수 있다는 비판이 계속되었고, 이에 2005년 8월 폐지되었다.

그런데, 소년법 제32조6호에서는 감호위탁처분을 규정하고 있고, 19세 미만의 소년들 중 비행청소년이 제32조6호 처분을 받을 경우 아동복지법에 따른 ‘아동보호치료시설’이나 법원이 지정한 ‘수탁기관’으로 보내고 있다. 소년법상 감호위탁처분은 비행청소년을 소년원이나 소년교도소와 같은 교정시설이 아니라 ‘아동복지시설’이나 ‘기타 소년보호시설’과 같은 개방시설에 수용한다는 점에서 사회내처우의 한 형태이다. 이는 기존의 교정

54) 배종대·홍영기, 「형사정책」, 홍문사, 2019, 466면.

시설이 아니라 민간시설에 수용한다는 점에서 교정의 민간화를 이행하는 것이면서, 교정 내 처우와 지역 사회에서의 처우 사이의 중간적 지대에서의 처우라는 성격을 갖고 있다.⁵⁵⁾ 「소년심판규칙」에서는 제1항, 제2항 및 제4항에 따른 위탁받는 기관 등은 소년에 대한 환경의 조정과 품행의 교정이나 보호자에 대한 특별교육에 적당한 곳이어야 한다고 규정하고 있다. 소년법상의 감호위탁처분은 이를 통해 소년이 건전하게 성장하도록 돕는 것을 목적으로 하고 있다. 이 같은 목적을 고려할 때, 감호위탁시설은 대상자들이 사회로 복귀할 수 있도록 적합한 시설과 교육 프로그램 등을 마련하는 것이 중요할 것이다.⁵⁶⁾

지금 논하고자 하는 가정폭력 가해자에 대한 감호위탁처분은 1997년 신설되었다. 가정폭력처벌법이 제정된 이후 사실상 감호위탁 처분은 집행된 적이 없어 사실상 사문화된 조항이었다. 그런데 최근 법무부가 감호위탁처분을 활성화할 목적으로 법을 개정하였다. 제정 당시 감호위탁처분의 주무부처는 법무부였으나, 법률상 가해자를 감호위탁할 시설은 법무부가 아닌 여성가족부가 주관하는 ‘가정폭력특례법이 정하는 보호시설’로 규정되어 있었기 때문에 법무부가 감호시설을 만들 수 없었던 바, 개정안에서 가정폭력 행위자에 대한 감호위탁 시설 마련의 주체를 ‘법무부 장관이 정하는 별도의 시설’로 변경한 것이다. 법무부는 법 개정에 따라 한국법무보호복지공단 16개 지부를 감호위탁 보호시설로 지정하였고, 최근 가정폭력 상습 가해자 두 명에 감호위탁처분을 부과하였다.⁵⁷⁾ 그런데 가정폭력 가해자에게 부과되는 이 감호위탁처분은 소년법을 교정시설에 수용하는 ‘중간적 처우’와 달리 가해자에 대한 제재적 성격이 더 강하게 드러나는 듯하다. 구 사회보호법에서 규정하던 보호감호는 이중처벌이라는 우려로 폐지되었지만, 소년법에서 규정하는 보호처분인 감호위탁처분은 사회로 복귀하기 전 중간지대에서 소년의 품행을 교정한다는 목적을 갖고 있어 정당화 근거가 있었다. 소년법의 감호위탁시설은 복지부에서 감독하는 개방시설이고, 가정폭력법상 감호위탁시설은 법무부에서 정하는 위탁시설로 큰 차이가 없어 보이나, 소년법의 감호위탁처분은 다른 처우보다 복지적 성격이 강하다.

55) 박영규, “보호시설 감호위탁처분(6호 처분)의 개선방안”. 법학논총, 제19권 제1호, 2012, 416-419면.

56) 박영규, 같은 논문, 416-419면, 417면.

57) 조선비즈, 2023. 6. 18., “가정폭력 가해자 분리·수용된다... 법무부 “감호위탁 활성화”, https://biz.chosun.com/topics/law_firm/2023/06/18/VBCEDKKZYBCLXFGIKKBTLTUGAQ/ (최근방문일 2023년 12월 22일).

대상자도 비행정도가 낮지만 보호자나 가족이 없어 무위탁 소년으로 방치하면 비행반복의 위험성이 크거나, 소년이 재범하였고 개선가능성은 있지만 보호자나 가족의 보호능력이 미약한 경우 등으로 다소 긍정적인 보호에 의한 선도를 기대할 수 있는 소년 등이다. 물론 비행성 있는 소년을 대상으로 하므로 순수한 의미의 아동복지지원은 아니지만, 안정적인 가정의 역할을 할 대체시설로서 기능한다는 점에서 보호처분으로서의 역할을 수행한다.⁵⁸⁾

그런데 가정폭력에서 규정하는 감호위탁처분은 제재의 중대함에 상응할 정당화 근거는 이보다 미약하다. 현행 규정을 보건대 대상자를 어떻게 선정할지, 그 목적을 무엇인지 구체화하기 어렵다. 소년범의 감호위탁처분이 소년을 재사회화하여 사회로 복귀시킨다는 목적을 갖고 있듯 가정폭력처벌법도 시설의 목적과 운영에 대한 규정을 보다 구체화하여야 법적 정당성을 강화할 수 있을 것이다. 그러나 궁극적으로는 가정폭력처벌법상 감호위탁처분은 가정보호사건(민사판결)에 의한 형사구금적 성격이 강하다고 생각된다. 요건을 구체화하거나 절차적 정당성을 강화하더라도 법치국가적 원칙을 고려하건대 이 같은 조치가 타당한지 의문을 완전히 제거할 수 없다. 그 법적 정당화에는 한계가 있을 것으로 생각된다.

V. 법체계의 정당성을 위한 제언

1. 가정폭력처벌법과 스토킹처벌법에 관하여

친밀한 관계의 폭력을 다루는 법적 규율은 피해자에 대한 실질적인 보호를 위해 국가의 적극적인 개입을 요청하고 있어 엄벌주의 경향, 관계의 특성을 도외시킨 내용적 유사성의 강화는 계속될 것으로 보인다. 그 실효성과 함께 법적 정당성에 대한 고려도 필요한 바, 결론에 갈음해 그 정책적 방향성에 관해 제언하고자 한다.

최근 현행 정책이 피해자 보호를 위해 규정하는 여러 제도적 장치들은 전반적으로 형

58) 이승현, “아동복지시설 위탁처분(6호)의 문제점과 개선방안”, 소년보호연구 제15권, 2010, 255-256면.

벌과 강력한 제재 부과에 치우쳐 있는 듯하다. 피해자의 신변보호를 위한 여러 조치들도 도입 및 보완되었으나, 제재적 성격이 보다 강화된 조치들이 두드러진다. 본고에서는 이를 크게 가해자-피해자의 분리조치, 범죄예방을 위한 엄벌주의적 조치(반의사불벌죄의 폐지, 조치위반의 형사화), 형벌 이외의 제재(잠정조치로서의 전자장치부착, 가정폭력처벌법상 감호위탁처분)로 구분하였다. 이 같은 제도들이 피해자 보호를 위해 실효적일 수 있으나 법적 정당화를 위해 보다 제재적 성격은 완화되면서 실효적인 정책, 관계 특성을 고려한 방안을 우선적으로 고려하여야 한다.

분리조치의 경우 다른 조치에 비해 제재적인 성격은 완화되면서도 범죄예방을 위한 실효성이 높은 제도라고 생각된다. 특히 친밀한 관계에서의 폭력은 초기대응이 중요하므로 현재와 같이 분리조치를 강화하면서 가정폭력에서의 우선적 체포제도 도입을 고려해 볼 만하다. 물론 이로 인한 반작용이 있을 수 있으나 피해자 보호라는 목적을 달성할 수 있는 수단 중에서 최소침해적인 수단을 먼저 활용하는 것이 타당하므로 도입의 실익이 있다. 범죄예방을 위한 엄벌주의적 조치 역시 피해자 보호 목적의 실현을 위해 타당하지만, 이는 분리 조치와 달리 분명히 처벌의 영역에 있고, 목적이 우선시되는 상황에서도 형법의 원칙들을 고려할 필요가 있다. 반의사불벌죄의 폐지는 관계의 특성을 고려해야 하며, 가정폭력의 경우 개인의 의사와 선택권을 존중해야 할 영역이므로 이를 도입하기 어렵다고 생각된다. 조치위반의 형사화는 관계의 특성, 위반 조치의 경중, 체계정합성 등을 고려해 신중하게 접근해야 한다. 이들은 일률적으로 접근할 수 없는 영역임을 고려할 필요가 있다.

범죄예방과 재범방지를 위해 활용하는 형벌 이외의 제재도 엄격히 고찰해야 한다. 스토킹처벌법상의 위치추적 전자장치나 가정폭력처벌법의 감호위탁처분은 실효적일 수 있으나, 이들은 잠정조치나 보호처분으로 부과하기에는 지나치게 제재적 성격이 강하다. 특히 이들은 감시적이면서 인신구속적인 성격을 갖는 제재라고 볼 수 있는데, 형벌만큼이나 강력한 효과를 가짐에도 형벌이 아닌 조치로서 취해지기 때문에 정당성 면에서 문제의 소지가 크다. 따라서 이 같은 수단들은 다른 수단이 없는 경우 예외적으로 활용하도록 규정을 구체화해야 한다. 현재의 규정보다 적용요건을 엄격히 설정하거나 절차적 정당성을 보완하는 것이다.

국가는 피해자를 적극적으로 보호할 의무가 있지만, 그 방법을 가해자에 대한 제재

확장에서만 찾는 것은 안이한 접근이라 생각된다. 피해자 보호는 다양한 정책으로 추구할 수 있다. 초기에 범죄를 예방하기 위한 경찰의 적극적 활동과 치안유지를 위한 정책, 피해자에 대한 지원 등으로 이를 실현할 수 있다. 현재의 가정폭력“처벌”법은 새로운 구성요건의 규정이나 가중처벌 없이 가정폭력 범죄예방을 위한 행정조치, 법원의 조치, 그 불이행에 관한 죄를 민사처리에 관한 특례 등을 정하고 있는 법이다. 다시 말해 해당 법이 범죄 자체의 “처벌”에 방점을 두지 않는 이상, 피해자 보호를 실효적으로 달성하려면 이 법을 가정폭력방지 및 피해자의 보호에 관한 법률과 통합해 적극적으로 피해자 보호를 위한 지원을 담는 것도 타당하다.

스토킹처벌법 역시 친밀한 관계만을 규율하는 법이 아니며 친밀한 관계의 피해자 보호만을 다루지 않더라도 그 법적 정당성이 모호한 영역이 있음은 부정하기 어렵다. 따라서 피해자 보호에 실효적인 정책을 도입하여 친밀한 관계의 폭력 논의가 갖는 이념을 실현하면서도 법적 정당성이 모호한 정책은 문제 성격을 약화시키는 방향으로 바뀌나갈 필요가 있다. 이 같은 제언은 친밀한 관계의 폭력을 다루는 최근의 경향에 역행하는 것처럼 보이지만, 형사법의 근본원칙을 재확인할 것을 요청하는 것이다.

2. 데이트폭력처벌법의 도입

법으로 규정하기 모호한 영역을 포섭하는 것은 보다 신중한 고려가 필요하다. 이 같은 영역을 다루려면 그 정당성에 대한 깊이 있는 고찰이 필요하고, 애매한 경우에는 형법의 최후수단성 원칙을 우선적으로 고려하는 것이 타당하다. 앞서 논의한 것처럼 데이트폭력을 고찰할 때도 피해자 보호가 우선시되더라도 형벌의 과잉이 되지 않도록 기존의 정책을 개선하는 방향을 먼저 검토할 필요가 있다. 데이트폭력의 정의 문제는 데이트폭력처벌법의 도입에 있어 가장 큰 난점이다. 본고에서는 먼저 현행 규정으로도 연인 사이의 신체적·물리적 폭력을 처벌할 수 있고, 스톱킹 행위유형에 해당할 경우 스톱킹처벌법의 적용을 받을 수 있음을 논하였다. 따라서 이 법을 도입하려면 그 필요성을 분명히 확인해야 한다. 물론 친밀한 관계에서의 폭력 문제는 관계의 특성상 취약한 위치에 있는 피해자들을 보호하고자 하며, 이를 정책적으로 실현할 필요는 분명하다. 그러나 데이트폭력의 정의 문제는 법 규정의 명확성과 충돌한다.

본래적으로 데이트 폭력은 ‘데이트 관계’를 어떻게 이해하는지에 따라 달라질 수 있는 모호한 개념이다. 일반적으로는 “친밀한 관계 혹은 연애관계에 있는 연인 사이에서 발생하는 신체적, 정신적, 성적 폭력”으로 규정하고 있지만, 데이트폭력에 관한 여러 발의안을 살펴보면 ‘미혼 남녀 간의 연애관계’에 한정하지 않고 교제 중인 경우뿐 아니라, 과거에 교제했던 관계도 포함하는 등 다양한 상황을 담고자 한다.⁵⁹⁾ 그러나 교제 관계에 대한 법적 합의를 찾기 어렵다. 이 법을 도입한 해외의 경우 데이트관계의 개념 정의가 불명확하여 실무상 많은 혼란을 초래하는 경우가 있었음⁶⁰⁾을 상기해볼 필요가 있다. 친밀한 관계에서 피해의 예방이 우선순위는 분명하나, 법으로 규정하기 모호한 영역까지 법으로 규율하려 하는 것은 법의 명확성을 저해하며 법적 혼란을 초래할 수 있다는 것이 본고가 논의하고자 하는 바이다.

그럼에도 데이트폭력처벌법을 도입할 필요성이 있다면, 이는 엄밀히 범죄의 성부에 관한 것은 아니다. 다시 말해, 기존의 규정으로 채우할 수 없는 법적 공백이 있어 새로이 구성요건을 창설해야 하거나, 기존 규정보다 형을 가중해야 할 분명한 필요성이 있다고 볼 수는 없다. 이 법을 도입할 필요성은 앞서 논한 가정폭력처벌법의 필요성과 유사하다. 가정폭력처벌법이 범죄를 새롭게 규율해 처벌하는 것이 아니라 범죄예방을 위한 각종 조치와 그 위반에 대한 제재, 특례 등을 규정하는 것처럼 데이트폭력처벌법은 범죄예방을 위한 여러 조치를 적용할 필요가 있을 때 도입될 수 있다. 처벌에 대한 공백이 있는 것은 아니지만, 가정폭력처벌법이나 스토킹처벌법처럼 응급조치, 긴급임시조치, 잠정조치 등을 적용할 수 없는 경우가 있고, 이 같은 조치와 제재가 필요할 때 법의 필요성도 인정된다. 궁극적으로 데이트폭력처벌법은 피해자 보호라는 목적에서 법적 정당성을 찾을 수 있다.

그 필요성을 입증할 수 있다 해도 데이트 관계의 법적 정의에 대한 합의는 법 제정에서 가장 중요한 관문이다. 그런데 본질적으로 인적 관계는 법적으로 성립되는 관계가 아닌 이상 법적으로 정의할 수 없는 영역이며 이 같은 작업은 형법의 한계영역이기도 하다. 또한 데이트폭력을 막기 위해 실현해야 할 정책들이 반드시 형법을 수단으로 해야 하는 것은 아니며, 형법은 최후수단적임은 중요하다. 이 같은 법이 형법의 과잉이 되지 않으려

59) 김구슬, 같은 논문, 135면.

60) 홍영오·연성진·주승희, 같은 보고서, 362면.

면 법의 도입보다 우선적으로 정부와 시민사회가 피해자를 지원하고 적극적으로 보호할 다양한 정책을 고려해야 할 것이다.

참고문헌

〈단행본〉

배종대·홍영기, 『형사정책』, 홍문사, 2019.

〈논문 및 보고서〉

김구슬, “데이트폭력범죄에 대한 입법적 대응방안”, 이화젠더법학, 제9권 제3호, 2017.

김남규·박다윤·노희주·김도선·김연수, “스토킹 행위자 위치추적 전자장치 부착제도의 도입 쟁점과 과제”, 형사정책연구 제34권 제2호, 2023.

김잔디, “스토킹차별법상 스톱킹범죄의 성립요건 - ‘반복’의 판단기준을 중심으로 -”, 이화젠더법학, 제14권 제1호, 2022.

김지선·김영중·최지선·성유리·고기원, 『중형주의 형사제재의 실효성에 관한 평가연구 (Ⅱ)- 전자감독제도의 실효성 평가연구』, 형사법무정책연구원, 2021.

김효정, “젠더기반폭력으로서 친밀 관계 폭력의 특성과 쟁점: 현장의 지원 경험을 중심으로”, 한국여성학 제40권 제1호, 2024.

박영규, “보호시설 감호위탁처분(6호 처분)의 개선방안”. 법학논총, 제19권 제1호, 2012.

서경현, “이성관계에서 행해지는 데이트 폭력에 관한 연구의 개관”, 한국심리학회지: 건강 제14권 제4호, 2009.

송현건, “미국의 가정폭력범죄 의무체포제도에 대한 연구: 경찰 집행 매뉴얼과 제도 문제점을 중심으로”, 치안정책연구, 제34권 제3호, 2020.

이승현, “아동복지시설 위탁처분(6호)의 문제점과 개선방안”, 소년보호연구 제15권, 2010.

윤정숙·이승현·김미숙·김유경·김지민·박미랑, 『가정 내 폭력범죄 감소 및 예방을 위한 사회안전망 강화에 관한 연구』, 형사법무정책연구원, 2017.

윤정숙·장진환·임하늘·박혜림·김은기, 『고위험 성범죄자 거주지 제한 정책 연구』, 형사법무정책연구원, 2023.

허민숙, “국가가 초래한, 국가가 알지 못하는 위험: 친밀한 관계에서의 강압적 통제”, 한국여성학 제37권 제1호, 2021.

- 홍영오·연성진·주승희, 『여성 대상 폭력에 관한 연구- 친밀한 관계에서의 폭력을 중심으로 -』, 형사법무정책연구원, 2015.
- 황태정, “전자감독제도의 비교법적 검토와 시사점”, 아주법학 제11권 제1호, 2017.
- Breiding, M.J., Chen J., & Black, M.C., Intimate Partner Violence in the United States - 2010. Atlanta, GA: National Center for Injury Prevention and Control, Centers for Disease Control and Prevention, 2014.
- Flynn, S, Battered Woman’s Syndrome: A Tragic Reality, an Evolving Theory. Trinity Women & Gender Minorities Review, 3(1), 2019.
- Jordan, Carol E., “Intimate partner violence and the justice system: An examination of the interface.” Journal of interpersonal violence 19.12, 2004.
- David L. Faigman, The Battered Woman Syndrome and Self-defense: A Legal and Empirical Dissent, 72 Va. L. Rev. 619, 1986.

The Justification of Criminal Policy on Intimate Partner Violence

Kim, Haemi

Recently, discussions to respond quickly and efficiently to violence in family or romantic relationships have been actively developed. This type of violence such as domestic violence, dating violence, and stalking is called intimate partner violence. Research on intimate relationship violence points out that victims of violence have difficulty protecting themselves or seeking legal relief. In the past, these areas were considered to be respected as individual private areas. However, a social consensus is urging the state to actively intervene.

The laws governing violence within close relationships show similarities in legal structures and systems, and the similarities are gradually increasing. The Domestic Violence Punishment Act and the Stalking Punishment Act stipulate emergency measures by police as initial responses, and temporary measures requested by prosecutors, and impose penalties for violating the obligations imposed by measures. Discussions on enacting the Date Violence Punishment Act also follow this structure. In addition to the similarities, the strengthening of the tendency of strict punishment can be cited as a common trend. However, even though the need for national intervention is emphasized, effectiveness and legitimacy of the sanctions prescribed should be made carefully. It is reasonable for the state to actively intervene in violence within close relationships, but such policies should take into account the characteristics and differences of the relationship and carefully examine whether it is effective and legally justified.

❖ Key words: intimate partner violence, domestic violence, dating violence, stalking, location-tracking electronic supervision